

1500873-17.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carlos Eduardo D'Elia Salvatori

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... moita" e ele confessou a prática de tráfico. Afirmou que o local era conhecido como de tráfico de drogas, mas o acusado não era conhecido dele, testemunha. Verbalizou que o acusado foi encontrado a aproximadamente 10 metros das drogas, sendo que ele ficava sentado, deixando as drogas "na moita". Esclareceu que durante a campanha visualizou que duas pessoas foram atendidas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500873-17.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500873-17.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIAS NICOLAS AROER LEMOS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo D'Elia Salvatori

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de ELIAS NICOLAS AROER LEMOS DA SILVA, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 12 de abril de 2021, por volta das 15h15, na Avenida Sport Club Corinthians Paulista, 2370, Santo Antônio, Osasco/SP, trazia consigo, guardava, vendia e entregava para comercialização e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de venda e consumo de terceiros: (I) 4,8g de substância entorpecente denominada cocaína, dividida e acondicionada em 12 (doze) microtubos plásticos do tipo eppendorf e (II) 0,9g de substância entorpecente denominada cocaína na forma petrificada ("crack"), dividida e acondicionada em 08 (oito) invólucros plásticos. Houve a prisão em flagrante (auto à fl. 01), que foi convertida em prisão preventiva, por meio da r. decisão de fls. 61-62.

A denúncia foi recebida em 19 de abril de 2021 (fl. 79).

O réu foi devidamente citado e apresentou sua defesa preliminar, com pedido de liberdade provisória (fls. 124-123).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da custódia cautelar (fls. 138-

143).

Em 27 de maio de 2021, foi concedida a liberdade provisória, mediante o cumprimento de cautelares diversas da prisão (fls. 149-150) e em face de tal decisão o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, que foi provido, para restabelecer a prisão preventiva (fls. 173-185).

Em audiência de instrução, foram ouvidas 02 (duas) testemunhas arroladas pela acusação e procedido ao interrogatório do réu, tendo sido os depoimentos gravados por meio de sistema audiovisual (fls. 240/241).

Encerrada a instrução, foram abertos os debates orais.

O Ministério Público requereu a procedência, porque demonstradas autoria e materialidade, com a consequente condenação do réu, nos termos da denúncia. Requereu, ainda, a fixação da pena base acima do mínimo legal, em razão de as drogas encontradas em poder do réu ostentarem alto poder vulnerante. No mais, salientou que deve ser considerada a reincidência, na segunda fase da dosimetria penal, sem valoração da confissão espontânea, em solo policial, em razão da insuficiência dos depoimentos dos policiais e, ainda, porque houve retratação em juízo. Por fim, sustentou que, em razão da reincidência, não se pode cogitar de tráfico privilegiado, devendo o regime inicial de cumprimento de pena ser o fechado.

A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição, por insuficiência probatória. Acrescentou que a denúncia se baseou unicamente nos depoimentos dos policiais, o que no caso concreto mostrou-se insuficiente a embasar decreto condenatório, notadamente em razão da contradição havida entre tais depoimentos. Alternativamente requereu a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, a uma porque pequena a quantidade de drogas encontrada e a duas porque o próprio acusado informou ser usuário de drogas. Para o caso de não ser acolhida a tese de desclassificação, requereu a fixação da pena base no mínimo legal e que na segunda fase da dosimetria penal haja compensação entre a reincidência e a confissão em solo policial e, ainda, na terceira fase, a despeito da reincidência, fosse fixado regime diverso do fechado, porque pouca droga foi encontrada.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A existência do crime é comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 07-09), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10-11), pelo laudo de constatação preliminar (fls. 13-15 e 165-167), pelo laudo químico-toxicológico definitivo (fls. 150-152).

Contudo, a ação penal deve ser julgada improcedente, uma vez que não há provas suficientes da autoria do crime imputado ao réu, como se extraí da análise da prova oral coligida em juízo.

A testemunha Moisés de Paula Ferreira de Souza, policial civil, afirmou que a polícia recebeu uma denúncia anônima e saíram em diligência, em uma viatura descaracterizada, quando visualizaram o réu que recebia pessoas, pegava algo e entregava algo. Disse que abordaram o indivíduo e encontraram o entorpecente "na moita" e ele confessou a prática de tráfico. Afirmou que o local era conhecido como de tráfico de drogas, mas o acusado não era conhecido dele, testemunha. Verbalizou que o acusado foi encontrado a aproximadamente 10 metros das drogas, sendo que ele ficava sentado, deixando as drogas "na moita". Esclareceu que durante a campanha visualizou que duas pessoas foram atendidas pelo réu e saíram, sendo que o réu conversava com a pessoa, pegava algo, depois ia até a "moita", pegava algo e entregava à pessoa. Informou que o denunciante disse que quem comanda a "biqueira" são os irmãos Cirilo, dois traficantes ainda em investigação. Anotou que com o acusado foi encontrada a quantia de R\$ 53,00, que estava em seu bolso, sendo que a droga estava na moita. Disse que foi ele, testemunha, quem revistou o acusado, que disse que morava na favela da 13. Narrou que ficaram em campana a aproximadamente uns 15 ou 20 metros do acusado, do outro lado do córrego, dentro da viatura, e que as pessoas foram a pé até o acusado e não foram abordadas. Esclareceu que não tentaram abordar os usuários, pois, até dar a volta, não daria tempo e não havia policiais suficientes para isso. Pontuou que o acusado, na abordagem, não ofereceu resistência e que no momento da abordagem outras pessoas visualizaram o ocorrido,

pois estavam do outro lado do córrego, sendo que tentaram arrolar testemunhas, mas não conseguiram. Concluiu dizendo que a droga estava em uma moita e foi encontrada pelo outro policial, em uma sacola plástica.

Já a testemunha Sérgio Ribeiro, policial civil, narrou que foi recebida denúncia de que no local dos fatos se praticava tráfico e rumaram para lá, em uma viatura descaracterizada, ficando de campana à distância. Relatou que visualizaram uma pessoa do outro lado de um córrego. Disse que uma pessoa chegou, entregou algo ao réu, que foi até uma moita, pegou algo e entregou a essa pessoa, acrescentando que outra pessoa chegou e o ocorrido se repetiu. Afirmou que ele e seu colega abordaram o réu e encontraram com ele, em seu bolso, 8 pedras de "crack" e R\$ 53,00 em dinheiro e, embaixo da árvore, na moita, alguns tubos de cocaína, acrescentando que o réu confessou informalmente a prática da venda de drogas e que a droga estava em uma moita, embaixo de uma árvore, a menos de 5 metros do local onde o réu estava. Repisou que foi recebida uma denúncia anônima, de que no local havia uma pessoa traficando, acrescentando que não foi ele quem recebeu a denúncia, não sabendo se nela constava quem seria o "dono da biqueira". Disse que foi seu o parceiro quem fez a revista no acusado. Afirmou que encontrou droga embalada em "pinos", em uma sacola de plástico. Asseverou que visualizou duas pessoas indo comprar as drogas e que elas rumaram a pé. Narrou que foi seu parceiro quem fez a revista pessoal no acusado e pegou no bolso do réu dinheiro e droga. Esclareceu que a droga encontrada na moita estava embalada em pinos e estava em uma sacola de plástico. Pontuou que não abordaram os usuários porque vieram por uma viela e se tentassem abordá-los poderiam não pegar o traficante. Narrou que próximo ao acusado não havia pessoas, no momento da abordagem e não tentaram encontrar testemunhas presenciais, porque de pronto o réu confessou que estava há dois dias traficando, ganhando 15% do que faturava com as vendas, não indicando o dono do ponto nem para ele, testemunha, não se recordando se ele indicou tal pessoa a seu (da testemunha) parceiro policial. Por seu turno o réu, em seu interrogatório, descreveu que tinha ido comprar drogas, mas não conseguiu concretizar a compra. Afirmou que estava com R\$ 83,00 e que é apenas usuário e que no momento da abordagem o traficante correu e ele não correu porque era apenas usuário. Aduziu que não conhece "Cirilo". Esclareceu que esse dinheiro foi da venda de sucatas que fez ao Ferro Velho "O rei da Sucata" que fica próximo ao Cemitério Bela Vista. Negou que tenha narrado os fatos como consta no interrogatório perante a autoridade policial.

Pois bem.

O cotejo da prova oral não permite assegurar com a certeza necessária que se exige a um decreto condenatório. Isso porque, há contradição entre os depoimentos dos policiais em juízo.

Com efeito, enquanto o policial Sérgio Ribeiro afirmou que com o réu foram encontradas 8 pedras de "crack" e dinheiro, o policial Moisés de Paula Ferreira de Souza asseverou que ele próprio fez a revista pessoal no acusado e com ele encontrou apenas dinheiro, sendo que toda a droga teria sido encontrada na moita, a metros de distância do réu.

Ademais, o policial Sérgio declarou que não buscaram arrolar testemunhas presenciais da prisão em flagrante, porque o réu já havia confessado, ao passo que seu colega Moisés disse que tentaram arrolar testemunhas, mas não conseguiram.

Assim, apesar da costumeira credibilidade que este juízo sempre deposita aos sérios agentes da lei que laboram na cidade de Osasco, tenho por convicção que, no caso dos autos, houve contradição nos depoimentos prestados, em intensidade suficiente a não cancelar o decreto condenatório, em face do princípio do "in dubio pro reo". Friso que a inconsistência sobre onde estava parte das drogas não é ponto marginal, especialmente por ter partido de quem realizou.

Consoante já se disse, "A aplicação da máxima in dubio pro reo é decorrência lógica dos princípios da reserva legal e da presunção de não culpabilidade e, como tal, exige juízo de certeza para a prolação do juízo condenatório, sendo que qualquer dúvida acerca da materialidade e autoria delitivas resolvem-se a favor do acusado" (STJ, Ministro Marco Aurélio, Bellizze 5ª Turma AgRg no AREsp nº 63199/MG DJe 03/09/2013).

Ou seja, no caso, tenho por convicção que ausentes provas suficientes de que a

droga encontrada (na moita, próxima à árvore), pertencia mesmo ao acusado, não podendo embasar decreto condenatório nem mesmo a confissão havida em solo policial, desprovida, aliás, de assinatura de próprio punho, porque não encontra supedâneo nas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório.

Acresça-se que, em juízo, o autor sustentou que estava apenas se dirigindo ao local para adquirir drogas, apresentando, ainda, tese não inverossímil de que a pouca quantia em espécie que levava consigo era fruto da venda de materiais recicláveis. Sobre o tema, os seguintes precedentes:

"Apelação. Tráfico de drogas. Recurso da defesa. 1. Materialidade comprovada. Fundadas dúvidas com relação à autoria. Depoimentos contraditórios dos policiais civis. Inconsistências entre os relatos apresentados quando da lavratura do flagrante e as oitivas judiciais. Negativa do acusado não infirmada por outras provas. Ausência de provas da vinculação do acusado com os entorpecentes apreendidos. Dúvidas razoáveis que conduzem à absolvição. 2. Recurso provido." (TJSP; Apelação Criminal 1501748-56.2021.8.26.0228; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 31ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021).

"Apelação. Tráfico de drogas. Réu absolvido. Depoimentos contraditórios entre si e em relação ao que se dissera no auto de prisão em flagrante, Benefício da dúvida corretamente reconhecido. Recurso não provido." (TJSP; Apelação Criminal 0008558-85.2015.8.26.0405; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 11ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Osasco - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2017; Data de Registro: 05/07/2017).

"Apelação. Tráfico e associação. Absolvição. Necessidade. Policiais que não confirmaram a versão apresentada em solo policial e ainda apresentaram depoimentos contraditórios. Ausência de certeza. Apelo provido." (TJSP; Apelação Criminal 0057614-61.2010.8.26.0050; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro Central Criminal Barra Funda - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/05/2014; Data de Registro: 28/05/2014).

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Materialidade comprovada - Autoria que se mostra duvidosa - Apelante que negou a prática delitiva em todas as fases do processo - Depoimentos contraditórios dos policiais responsáveis pela prisão da ré - Conjunto probatório que não se mostra seguro a embasar a condenação. Recurso provido." (TJSP; Apelação Criminal com Revisão 0054421-43.2007.8.26.0050; Relator (a): Ericson Maranhão; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 12ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/08/2008; Data de Registro: 09/09/2008).

Nessa quadratura, outra solução não há, senão que a absolvição por insuficiência probatória a respeito da autoria, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e, por isso, absolvo o réu ELIAS NICOLAS AROER LEMOS DA SILVA, da prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA, devendo ser expedido, de imediato, o competente alvará de soltura.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P.I.C

Osasco, 20 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA